

1500329-19.2021.8.26.0125

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... para a condenação pelo crime de tráfico, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas. Há, contudo, certeza suficiente para a condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, nos termos da fundamentação acima.

Nesse contexto, dada a ausência de certeza quanto à prática de tráfico por parte dos acusados, a solução que melhor se delineia é a de desclassificação do delito. Nesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

2ª Vara

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari - SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500329-19.2021.8.26.0125 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500329-19.2021.8.26.0125

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, segundo narrou a denúncia, o réu no dia 11 de fevereiro de 2021, na Rua Francisco, nas proximidades do nº 59, Centro, na cidade e comarca de Capivari, o réu trazia consigo, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, um tijolo de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida por maconha, com peso líquido de 76,8 gramas, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de exame químico toxicológico em fls. 22/24. A denúncia foi oferecida em 05/03/2021 (fls. 27/30) e recebida em 30/06/2021 (fls. 42/45).

Citado, o réu apresentou sua defesa prévia às fls. 136/139.

Realizada a audiência de instrução e julgamento nesta data, foram ouvidas a duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em seguida, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório. Passo a fundamentar.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo

quaisquer preliminares alegadas pela Defesa ou pelo Ministério Público, passo, pois, a conhecer diretamente do mérito.

A denúncia é procedente em parte.

A materialidade delitativa se encontra devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 04 e laudos de fls. 22/24 e 33/35.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos.

Ouvido em juízo, o PM Matheus narrou, em breve síntese, que foi acionado via COPOM para averiguar indivíduos que estavam foragidos da justiça; que, chegando ao local, avistou o réu e este logo em seguida se pôs em fuga; que não sabe dizer se o local em que o réu foi avistado era conhecido como ponto de venda de drogas; que não havia outros indivíduos nas proximidades do réu; que não conhecia o réu; que o réu não estava foragido da justiça.

Ouvido em juízo, o PM Gustavo apresentou idêntica versão. Acrescentou que o réu era conhecido nos meios policiais como traficante.

Interrogado, o réu confirmou a apreensão das drogas; que comprou a droga para o seu consumo; que estava com a droga em seu bolso; que estava caminhando e foi abordado pelos policiais.

Inequívoca, portanto, a apreensão de drogas com o réu, conduta esta confessada por ele e confirmada pelos policiais.

Nesse sentido, não há qualquer dúvida de que o réu foi flagrado na via pública e detido na posse de 76,8 gramas (conforme quantidade exata indicada no laudo definitivo).

Ocorre que as circunstâncias da prisão não são reveladoras da finalidade de comércio.

Em primeiro lugar, constato que foi apreendida uma única porção de maconha. Embora a porção seja grande, passível de ser fracionada em algumas poucas individualizadas de maconha. Não se trata de grande quantidade de maconha que seria ainda separada em porções individuais para a venda.

Em suma, a quantidade de maconha não é compatível com maconha a granel, que seria separada para venda.

Em segundo lugar, o local em que o réu se encontrava não é ponto de venda de drogas, como categoricamente afirmou o policial militar Gustavo.

Em terceiro lugar, não havia qualquer outra circunstância reveladora da traficância, até porque a diligência policial teve início para apurar possível presença de foragidos da justiça.

O que se tem, nos autos, é apenas a apreensão de uma quantidade de drogas que não evidencia por si só a traficância. Ante a inexistência de outras circunstâncias que façam presumir que as drogas se destinavam ao comércio ilícito, não há certeza para a condenação pelo crime de tráfico, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas. Há, contudo, certeza suficiente para a condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, nos termos da fundamentação acima.

Nesse contexto, dada a ausência de certeza quanto à prática de tráfico por parte dos acusados, a solução que melhor se delineia é a de desclassificação do delito.

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PORTADA POR UM DOS ACUSADOS, EM QUANTIDADE RAZOÁVEL PARA UM CONSUMIDOR. A SOLUÇÃO ADEQUADA É A DESCLASSIFICAÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO HÁ, NA LEGISLAÇÃO ATUAL, DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, APENAS MITIGAÇÃO DA PENA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS EDUCATIVAS. Apelo parcialmente provido.” (Apelação Crime Nº 70018719609, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Julgado em 07/11/2007).

Com razão, nota-se que as alegações finais do Ministério Público fundamentam-se única e exclusivamente em fatos novos trazidos pelo próprio réu mas sem qualquer amparo em outras provas e desconectados com os fatos tratados neste feito. Mesmo que confesse crimes outros, o réu responde por uma única infração, qual seja, a apreensão da porção singular de maconha apreendida nestes autos.

Diante disso, não havendo dúvidas de que o réu portava drogas para consumo próprio, já que, em razão da quantidade de drogas, bem como da conduta do réu por ocasião de

sua detenção, é de rigor o reconhecimento da infração pena praticada.

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM".POSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A

PRÁTICA DO CRIME DE USODE ENTORPECENTES. NÃO HOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA

INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO.IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em

descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF.

Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Pelos argumentos acima, entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A infração penal do art. 28 da Lei de Drogas prevê as seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, sendo certo que as penas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

Como se nota, as sanções previstas na lei penal tem especial diretriz educadora, privilegiando, sem dúvida alguma, a prevenção geral e especial positiva – em suma, a norma revela uma preocupação exclusivamente ressocializadora e curativa, com o fim de afastar o usuário do convívio das drogas.

Em outras palavras, o preceito secundário do art. 28 da Lei de Drogas não revela qualquer caráter retributivo ou preventivo negativo.

Diante dessas premissas, a dosimetria da pena, para o tipo penal em questão, não atende ao critério da proporcionalidade à luz da reprovabilidade da conduta, que atua como diretriz da dosimetria da pena conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do sistema trifásico do art. 68, também do Código Penal. Assim, atento ao critério específico da dosimetria do art. 28 da Lei de Drogas, o qual privilegia a ressocialização e cura do usuário de drogas, entendo que a fixação da pena de advertência se revela como a mais adequada, diante da baixa probabilidade de eficácia concreta de qualquer outra medida.

De fato, o encaminhamento e a frequência a tratamento médico somente se revele eficaz se é realizado por espontânea vontade. A manutenção de qualquer indivíduo, contra a sua vontade, em qualquer programa dessa natureza, não revela qualquer resultado prático.

Assim com a prestação de serviços à comunidade, que não tem o condão de afastar o usuário da drogadição, representando, na realidade, verdadeira retribuição pela conduta praticada, o que também se revela ineficaz para a solução da drogadição do condenado.

Até porque, muito embora a pena de prestação de serviços à comunidade revele certa proporcionalidade em relação à conduta praticada, na prática ela se mostra completamente inócua diante da impossibilidade de conversão da pena de prestação de serviços em privativa de liberdade, apenas onerando ainda mais o erário com a manutenção de um processo judicial que não surtirá efeito prático algum. De fato, a prática vem demonstrando que, intimado a dar início ao cumprimento da pena, diante da completa falta de consequência pela não prestação dos serviços a que foi condenado, os condenados simplesmente a ignoram, especialmente nos casos em que ele

responde ou respondeu a processos por crimes mais graves, quadro este que apenas contribui com o aumento da despesa na manutenção do processo judicial. Dito isso, entendo pela aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Decido.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JONATAS DIVINO GAVIÃO RIBEIRO como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Caso ainda não tenha sido realizada tal providência, nos termos do art. 50, §3º, da Lei 11.343/06, autorizo a destruição das drogas apreendidas, com a ressalva das amostras guardas para contraprova. Cópia digitalmente assinada da presente sentença valerá como ofício à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, fica desde já autorizada a destruição das amostras guardas para contraprova, oficiando-se para tanto.

Expedição de certidão do Convênio OAB/DPE. Em caso de defesa patrocinada por meio do Convênio OAB/DPE, aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários (para pagamento de 100% do valor previsto na tabela). Na hipótese de interposição de recurso por qualquer uma das partes, expeça-se certidão de honorários, observando-se a seguinte regra do Convênio: “nos processos criminais de competência do Juízo singular, após a sentença condenatória ou absolutória com interposição de recurso por quaisquer das partes, 70% (setenta por cento) do valor previsto na tabela por ocasião da sentença e, os 30% (trinta por cento) restantes, após o trânsito em julgado do acórdão.”

Após o trânsito em julgado, (a) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); e (b) expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Capivari, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA